



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12
מס' בקשה: 81/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: מעין בר
הנתבעת 2: ע"י ב"כ עוה"ד אביחי ברטנובסקי
מרחוב פרופ' שור 7 תל אביב

נ ג ד

המשיבה 1: נציגות הבית המשותף רחוב לואי מרשל 5-7 תל אביב
התובעת: ע"י ב"כ עוה"ד אופיר מילר
מרחוב בלוח 2 תל אביב

המשיב 2: חנניה אוסטון
הנתבע 1: ע"י ב"כ עוה"ד אשר נחתומי
מרחוב המסגר 55 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לעיכוב ביצוע של החלטתי מיום 29.07.12 (להלן: "ההחלטה") עקב כוונת המבקשת לנקוט בהליכי ערעור לבית המשפט המחוזי בנוגע להחלטה זו.

בהחלטה קיבלתי את בקשת המשיבה 1 ונתתי צו מניעה האוסר על הנתבעים (המבקשת והמשיב) לעשות כל שימוש ייחודי בתחום שטח הקולונדה המסומנת בתשריט הבית המשותף ובכלל האמור אסרתי עליהם להציב בשטח האמור שולחנות וכסאות ו/או מתקנים כלשהם, מקובעים או ניידים, לרבות, מצלמות, וזאת עד להכרעה בתובענה העיקרית.

כלל הוא, בהתאם להוראות תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"), כי עצם נקיטת הליכי ערעור איננה מעכבת את ביצוע ההחלטה נשוא הערעור. יחד עם זאת, בהתאם להוראות תקנות 467 ו-468 לתקנות, ניתן לבית המשפט שיקול דעת להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין וזאת כאשר מבקש העיכוב משכנע את בית המשפט כי נתמלאו שני קריטריונים עיקריים והם:

כי יש לו סיכויים טובים לזכות בערעור.

כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, בין היתר, בשל כך שאם יתקבל הערעור, ייגרם למבקש נזק בלתי הפיך או קושי משמעותי בהשבת המצב לקדמותו.

שני הקריטריונים הנ"ל משפיעים האחד על השני. ככל שסיכויי הערעור נמוכים, גובר הנטל על מבקש העיכוב לשכנע כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. מאידך, כאשר ביצוע מידי של ההחלטה עשוי לייתר את הערעור, שאיננו חסר סיכוי, יש הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין, כדי למנוע שינוי במצב הקיים וסיכול תוצאות הערעור והפיכתו לאקדמי. כאשר כפות המאזניים שוות, ועשוי להיגרם נזק לשני הצדדים, הרי שיש להעדיף את הכלל הבסיסי לפיו יש לקיים את ההחלטה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12
מס' בקשה: 81/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נוכח טיבה וטבעה של החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע, רצוי שבית המשפט לא ינקוט עמדה נחרצת מעבר להתרשמות על פני הדברים אולם הנטל על מבקש העיכוב אינו קל. (ראו סיכום ההלכות בש"א 86/89 הרפז נ' אחיטוב פ"ד מג(1) 334; בש"א 3158/91 ע"א 2464/91 פלסו שרון ואח' נ' קומפני פריזיין ואח', פד"י מה(5) 499; ב"ש 227/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ פ"ד מא(1) 713; ע"א 6824/97 יעקב בן שחר נ' גיל סוחה ואח' (פורסם בנבו); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) 674).

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אינני מוצא מקום להיעתר לבקשה.

כבר כאן המקום להעיר כי תשובת המבקשת לתגובת המשיבה חרגה מגבולות המותר. אין כל הגיון בכך שתשובה שאורכה כ- 4 עמודים תזכה לתגובה בת 63 סעיפים. למעשה, התשובה לתגובה היתה ארוכה יותר מאשר הבקשה עצמה. אין תשובה לתגובה יכולה להיות מקצה שיפורים לבקשה וגם אין צורך במסגרתה לחזור שוב על טענות שהועלו כבר.

לא מצאתי כי למבקשת סיכויי ערעור טובים.

המדובר בהחלטה בבקשה למתן צו מניעה זמני ולא בפסק דין בתיק העיקרי. משכך, כל טענות המבקשת בדבר שגיאות, לכאורה, בהחלטתי, אינן ממנ העניין שכן אלו טרם הוכרעו - טרם הוכרע באם השימוש אותו מבצעת המבקש בשטח הקולונדה הינו שימוש סביר ובכלל האמור טיב ואופי השימוש בבית הקפה. טרם הוכרעו טענות המבקשת כי שטח הקולונדה אינו בגדר רכוש משותף. כך גם טרם הוכרעו טענות המבקשת בנוגע לסמכות הנציגות.

בהתאם להוראות הדין כל שנדרש בשלב התחלתי זה של ההליך הוא קיומן של "ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת תביעה" (תקנה 362(א) לתקנות). לא ברורה טענת המבקשת בסעיף 7.11 לבקשתה כי המבחן האמור, **הקבוע במפורש בהוראות התקנות**, אינו נדרש לצורך מתן הסעד הזמני.

מכל מקום, ברי כי במקרה דנן התנאי מתקיים, כפי שנקבע בהחלטה - מתוך מסמכי רישום הבית המשותף עולה כי שטח הקולונדה מצוי בתוך שטח קונטור הבית והינו רכוש משותף. אין מחלוקת גם כי בידי המבקשת אין הסכמה של בעלי הדירות לשימוש המבוקש. די בכך לקיום התנאי הנדרש כאמור, בפרט כאשר עסקינן בתביעה בפני מפקח על רישום מקרקעין (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

וידגש, בניגוד לטענות המבקשת בתשובה לתגובה, הרי שלא רשומה כל זיקת הנאה או כל זכות קניינית אחרת בקולונדה לטובת הרשות המקומית. ויוער, אף אם היתה רשומה זיקת הנאה, הרי שזו לא יכולה היתה להקנות לרשות המקומית את הזכות לאשר הצבת שולחנות וכסאות בשטח זה (ובפרט לטובת שימוש מסחרי שאין מחלוקת שמבוקש לבצע) שהרי זיקת הנאה איננה אלא "שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם" (סעיף 5 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12
מס' בקשה: 81/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מכל מקום, הליכי התכנון יכולים להשפיע על אשר יבנה בנכס או על השימוש שיבוצע בו. אולם, אין באלו כדי להשפיע על הבעלות בו אלא באמצעות ההליכים המוסדרים בחוק, ועל פי המרשם אלו לא ננקטו במקרה דנן. משכך, כל עוד נותרו בעלי הדירות בבית כבעלים של שטח הקולונדה, זכאים הם להחליט על אשר יעשה בה, בכפוף למותר על פי דיני התכנון (ולפיכך טענות תיאורטיות של המבקשת בדבר סגירת הקולונדה על ידי הנציגות אין בהן דבר). אולם, אף אם ניתן על פי דיני התכנון להציב כסאות ושולחנות בשטח זה, אין דינים אלו, ובודאי שלא הרשות המקומית (בשטח שאין לה כל זכויות קנייניות בו) יכולים להתיר שימוש מסחרי בנכס ללא הסכמת בעלי הנכס.

אעיר כי אין בהחלטה (שממילא איננה בגדר פסק דין) לשנות "את חיי המסחר בתל אביב", שהרי ההחלטה מבוססת על הוראות הדין במדינת ישראל, החלים גם בתל אביב. ממילא ההחלטה גם תואמת את "חיי המסחר בתל אביב" (ראה עש"א (מחוזי - ת"א) 11-01-36094 הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 (טרם פורסם)).

אין הבקשה מלמדת על כי שגיתי בהערכת מאזן הנוחות שבין הצדדים. ההחלטה מנומקת בהקשר זה ואין די בחזרה על טענות שנטענו ונדחו כדי לבסס סיכויי ערעור. בסופו של יום המדובר ברצונה של המבקשת (שאינו מוכחש) לעשות שימוש מסחרי בשטח המחלוקת – הושבת סועדים, סוככים, אדניות, מצלמות, כל זאת ללא הסכמה של בעלי הדירות בבית.

ויוודגש, טענת המבקשת כי המדובר במטרד צפוי בלבד שאינו מצדיק מתן צו מניעה זמני אין לה על מה שתסמוך. המשיבה טוענת כי תגרם הפרעה עקב השימוש המסחרי ומצאתי טעם בטענתה זו בשקילת מאזן הנוחות שבין הצדדים. אם אכן אין כל הפרעה בשימוש, סביר כי היתה מוצאת המבקשת ולו חלק מבעלי הדירות אשר היו מסכימים לשימוש המבוקש על ידה. מטרתו של הצו הזמני הינה הקפאה של המצב העובדתי, כפי שהוא, עד להכרעה בתובענה העיקרית. קבלת טענת המבקשת תביא, למעשה, למצב בו כל בקשה למתן צו מניעה זמני ניתן יהיה להגיש רק לאחר ביצוע השימוש בפועל. כך, לכאורה, גם במקרה בו מבוצעים שינויים ברכוש המשותף כגון הרחבת דירה, פתיחת חלון וכיוצ"ב, שהרי את ההפרעה מאלו ניתן יהיה להסיק, לגישת המבקשת, רק לאחר ביצועם בפועל. אין בטענה זו כל היגיון או הצדק.

ויוער, המבקשת דנן טוענת כי הבקשה הוגשה בשיהוי שכן היה על המשיבה להגישה לכשנודע לה על כוונתה לעשות שימוש בשטח הקולונדה - מה היתה טוענת המבקשת לו היתה מוגשת הבקשה אז בכל הקשור להפרעה הצפויה משימוש (כאשר אפילו לא היה ידוע איזה שימוש מבוקש לבצע)? מה היתה טוענת בכל הקשור לשיהוי אם היתה מוגשת הבקשה רק לאחר תחילת השימוש בפועל (כטענתה בבקשה דנן)?

אולם, חשוב מכל האמור, הרי שאין בבקשה כל טענה כי שגיתי בקביעתי כי הבקשה נועדה על מנת לשמר את המצב הקיים. אין מחלוקת כי עובר להגשת הבקשה לא פעל בית הקפה בכלל, ובפרט לא נעשה שימוש מסחרי בשטח הקולונדה, כפי שמאשרת המבקשת שבדעתה לבצע. על פי הבקשה רק ביום 31.07.12 אמורה היתה להתקיים קבלת פנים לרגל פתיחת בית הקפה (סעיף 6 לבקשה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12
מס' בקשה: 81/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות שכאלו, צו המניעה הזמני ניתן כדין ובמועד על מנת לשמר את המצב הקיים עד להכרעה בתובענה. צו זה גם נדרש במקרה דנן, ולראיה, לאחר הדיון בבקשה, עוד בטרם ניתנה החלטה (שעה שהצדדים אמורים היו לבוא בדברים) התקינה המבקשת ציוד נוסף ברכוש המשותף (אדניות).

ויודגש, אף אם משמעות מתן הצו הינה עיכוב בפתיחת בית הקפה, הרי שאין מנוס מכך. אם בסופו של יום תתקבל התביעה, הרי שממילא לא נגרם למבקשת כל נזק, שהרי במקרה שכזה היא מלכתחילה לא היתה זכאית לבצע שימוש ברכוש המשותף כפי שתכננה. אם בסופו של יום תדחה התביעה, הרי שכל הנזקים שיגרמו למבקשת ניתנים לשיפוי. כך הם פני הדברים בכל מקרה בו ניתן סעד זמני - בכל סעד זמני שניתן יש משום הפרעה או נזק למשיב. במידה והתובענה נדחת זכאי המשיב לשיפוי בגין נזקים אלו, והרי לשם כך נועדו הבטוחות שעל המבקש להגיש ביחד עם הבקשה (תקנה 364 לתקנות).

אעיר גם כי לא מצאתי כי יש במתן צו המניעה משום הוראה לסגירת בית הקפה, שממילא, על פי טענת המבקשת, רק אמור היה להיפתח ביום 31.07.12 כאמור. **אין בהחלטה כל איסור על ביצוע שימוש בשטחים שאינם חלק מן הרכוש המשותף ובודאי שאין בצו איסור על פתיחת בית הקפה.** הטענות בדבר אובדן וירידה לטמיון, על פניהן, מוגזמות.

לא מצאתי גם כי יש טענות של ממש בכך ששגיתי בקביעתי כי לא היה שיהוי בהגשת הבקשה. ה"היגיון, הצדק או הדין" הם שלא להאין באנשים להגיש תובענות בפני ערכאות משפטיות, ובודאי שלא צוי מניעה זמניים, אלא כאשר ברור כי אשר הם מבקשים למנוע עומד להתרחש. על אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר המדובר בסכסוכים שבין שכנים בבית משותף וכאשר המבקשת ידעה על התנגדות לשימוש המתוכנן בשטח הקולונדה. ממילא, לא יכולה היתה המשיבה להגיש הבקשה במועד מוקדם יותר, כי שפסקתי בהחלטה.

המבקשת לא טענה בבקשתה כי מאז הנוחות בבקשה דנן נוטה לטובתה – לא מצאתי כי המבקשת הראתה שאם יתקבל הערעור ולא יעוכב ביצוע ההחלטה, ייגרם לה נזק בלתי הפיך או קושי משמעותי בהשבת המצב לקדמותו. גם לא מצאתי כל טענה כי אי עיכוב ביצוע ההחלטה עשוי לייתר את הליכי הערעור. לא בכדי לא נמצאו טענות אלו - המדובר בהליכי ערעור על החלטה בבקשה למתן צו מניעה זמני ולא בהחלטה הקובעת מסמרות בתיק העיקרי. אם יתקבל הערעור הרי שיבוטל הצו הזמני והמבקשת תוכל בנקל לעשות שימוש בשטח הקולונדה (כשם שבנקל, לשיטתה, חדלה מלעשות שימוש זה לאחר קבלת הצו) וממילא לא אבדה כל השקעה שביצעה.

ויודגש, לא ניתן כל צו המורה על סילוק מתקנים שהותקנו אלא אך נאסרה התקנתם של מתקנים נוספים והצבת שולחנות וכסאות בשטח הרכוש המשותף (מעשה יומיומי). ממילא, כל נזק שיגרם עד לקבלת הערעור על ההחלטה, אם יתקבל (והסיכויים לכך קלושים), ניתן גם הוא לשיפוי כספי.

בתשובה לתגובה כאמור הוסיפה המבקשת טענות בנוגע למאזן הנוחות. אף שלא היה מקום להוסיף טענות אלו במסגרת תשובה לתגובה (שהרי אלו צריכות היו להיכלל כבר במסגרת הבקשה), הרי שבחינה של אלו מלמדת כי עניינן, בעיקר, במאזן הנוחות שבין הצדדים, בנוגע למתן צו המניעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 325/12
מס' בקשה: 81/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ולא בנוגע למאזן הנוחות שבחינתו נדרשת לצורך החלטה בבקשה דנן לעיכוב ביצוע. בין השניים יש הבדל משמעותי.

בהקשר זה אין בידי לקבל את הטענה כאילו דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע משמעותה מתן הסעד הסופי המבוקש בתובענה- טענה זו איננה יכולה להישמע כנגד החלטה בבקשה דנן, שהרי עיכוב ביצוע לעולם אינו הבסיס לסעד המהותי אלא אך מעכב ביצוע של חיוב פסוק. גם כנגד ההחלטה אין מקום לטענה זו, שעה שהסעד הזמני שניתן מטרתו אך לשמר את המצב הקיים עד להכרעה בתיק העיקרי. כמו כן, בתיק העיקרי נתבקשו סעדים נוספים אשר טרם נדונו, בנוגע לעבודות ומתקנים שהציבה המבקשת ברכוש המשותף.

אין בידי גם לקבל את הטענה כי משמעות דחיית הבקשה דנן היא "החרבתו" של בית הקפה- ההחלטה איננה ממונעת הפעלתו של בית הקפה ובתוך כך צמצום הנזקים, לכאורה, שעשויים להיגרם למבקשת. ההחלטה אך משמרת את המצב הקיים עובר לפתיחת בית הקפה, עד להחלטה תיק העיקרי. ויודגש, **בית הקפה לא פעל, ובודאי שלא עשה שימוש מסחרי בשטח הקולונדה עובר להגשת הבקשה ולמתן ההחלטה** (כטענת המבקשת עצמה כאמור לעיל). בנסיבות שכאלה הרי שהטענה כאילו דחיית הבקשה דנן או אפילו הותרת ההחלטה על כנה יביאו לקריסה כלכלית מוחלטת של בית הקפה אין בה דבר. ממילא הטענות בדבר נזקים כלכליים לכאורה או השקעות שירדו לטמיון לא נתמכו בכל ראייה, לא במסגרת תיק הבקשה למתן הסעד הזמני, לא במסגרת הבקשה דנן וגם לא בתשובה לתגובה.

לפני סיום אציין כי הסכמתו של המשיב לבקשה אין בה להעלות או להוריד. המשיב הינו הבעלים של הנכס בו מפעילה המבקשת את בית הקפה. משכך, הינו נתבע נכון ודרוש בתובענה דנן. אומנם, בדיון מיום 15.07.12 טען המשיב כי כל אשר יוכרע בין המבקשת למשיבה מקובל עליו. אולם, הן בכתב ההגנה מטעמו והן בתגובה מטעמו לבקשה דנן נוקט הוא עמדה המחייבת נוכחותו בהליך. תמוהה הטענה בתגובת המשיב כי יש לעכב את ביצוע ההחלטה עד לפסק הדין בתובענה - המדובר בהחלטה בבקשה למתן צו זמני ולפיכך, עיכוב ביצוע החלטה זו עד למתן פסק הדין סותר, מניה וביה, את עצם מטרת הצו.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע של ההחלטה.

המבקשת תשלם למשיבה 1 סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות הבקשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה בלשכתי היום כ' אב תשע"ב, 08 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב